

1500249-70.2022.8.26.0626

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecente TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - O testemunho dos policiais tem validade como qualquer outro - Depoimentos coerentes - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500249-70.2022.8.26.0626 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500249-70.2022.8.26.0626 - Controle nº 2022/001166

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILMAR MARTINIANO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLAUCIA FERNANDES PAIVA

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada às fls. 70/71, no dia no dia 03 de junho de 2022, por volta das 12:34 horas, na Rua Arthur Leal, nº 64, Praia de Boiçucanga, nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, SILMAR MARTINIANO, qualificado à fl. 04, trazia consigo e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega a consumo de terceiros, 378 (trezentos e setenta e oito) porções de cocaína, na forma de crack, com peso bruto aproximado de 234,58g (duzentos e trinta e quatro gramas e cinquenta e oito centigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 10, auto de constatação preliminar de fl. 13 e laudo pericial toxicológico requisitado a fl. 14, que será oportunamente juntado aos autos.

Em razão destes fatos, o réu SILMAR MARTINIANO, qualificado à fl. 04, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida (fls. 77/78) e o réu citado (fl. 87). Sobreveio resposta à acusação (fl. 92/99), com manutenção do recebimento da denúncia (fls. 107/108). Houve a realização de audiência de instrução (fls. 159/165), com a oitiva de quatro

testemunhas, bem como procedeu-se ao interrogatório do réu.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, nos exatos termos da denúncia, em razão do conjunto probatório, em especial o depoimento dos policiais militares, ouvidos em juízo.

Ao passo que a Defesa pugnou pela absolvição do réu por ilicitude das provas, em especial a entrada dos policiais militares sem autorização..

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Rejeito, de logo, a preliminar de violação de domicílio e prova ilícita arguida pela d. Defesa em sede de Alegações Finais, que aduziu que restou comprovado que o ingresso dos policiais militares na residência do acusado se deu de maneira ilegal, pois não houve autorização para o ingresso na residência dele, devendo, portanto, ser declarada nula todas as provas produzidas decorrente de tal ilícito.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê no artigo 5º, inciso XI, dentre os direitos e garantias fundamentais, que "a casa é asilo inviolável do indivíduo", elencando, ainda, algumas hipóteses nas quais se admite exceção a tal princípio, sendo elas: em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, em qualquer horário. Fora de tais hipóteses, somente é permitido o ingresso na residência do indivíduo, sem o seu consentimento e durante o dia, por determinação judicial.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que o tráfico de drogas, por ser crime permanente (aquele cuja consumação se prolonga no tempo), admite o flagrante a qualquer momento. Desse modo, o agente que guarda ou tem em depósito substâncias entorpecentes está continuamente em flagrante delito.

Nesse sentido, segue jurisprudência recente:

"1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizara prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.2. No caso, o paciente foi acusado de praticar o crime de tráfico na modalidade guardar e manterem depósito substâncias entorpecentes, estando-se diante de ilícito de natureza permanente, o que legitima a medida adotada" (HC 373.388/RS, DJe 01/02/2017).

"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, prescindível o mandado de busca e apreensão, bem como a autorização do respectivo morador, para que policiais adentrem a residência do acusado, não havendo falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida (HC 345.424 /SC, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA, j. 18/08/2016, DJe 16/09/2016)" (HC 326.503/RS, DJe15/03/2017).

Desse modo, não houve a violação de domicílio por parte da polícia, que teve autorização do réu para adentrar o imóvel. Caso tal autorização não tivesse sido proferida, a prática de crime de tráfico de entorpecentes ou de posse ou porte de entorpecentes para uso pessoal autorizam o flagrante a qualquer tempo, por se tratarem de crimes permanentes, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal.

Quanto ao mérito, o pedido formulado na presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está estampada no boletim de ocorrência (fls. 07/08), laudo de constatação (fl. 13), relatório policial (fls. 43/44), laudo químico toxicológico (fls. 122/124) e prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria é igualmente certa e repousa sobre o réu.

O policial militar Diogo Alves, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que houve denúncia via 190 informando que o "indivíduo" Silmar estaria traficando na Rua Tropicanga, atual Rua Arthur Leal. Como já havia efetuado a prisão do réu anteriormente, já sabia quem era a pessoa. A equipe se dirigiu ao local e efetuou a abordagem do réu, que continha uma quantia de entorpecentes. O

acusado confessou que tinha mais entorpecentes em sua residência, disse que não era responsável pela venda mas para a entrega das drogas aos vendedores. O local dos fatos tem um ponto de drogas bem perto, numa distância de 100, 150 metros, contudo o réu é conhecido na região por venda de entorpecentes. O remanescente das drogas foi encontrado em uma caixa de som, dentro da residência do Silmar. Às reperguntas da Defesa disse o réu foi abordado na via pública, em frente à barbearia que trabalha. A residência fica no fundo da barbearia, local onde o restante dos entorpecentes foi localizado. O direito de permanecer em silêncio foi informado, mas não se recorda quem informou. A abordagem foi feita com base na denúncia via 190, sendo que já conhecia o réu de ocorrências anteriores.

O policial militar Marcelo José Ferreira, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que atendeu a ocorrência efetuada via COPOM, tendo sido indicado o réu. No momento da abordagem, foi encontrado pedras de crack, sendo que o réu indicou que tinha mais drogas em sua residência. Houve o encontro de mais entorpecentes dentro de uma caixa de som, na residência do réu. Às reperguntas da Defesa disse o réu foi abordado em frente ao imóvel de sua residência, sendo que tem uma barbearia na frente e a casa é nos fundos. A barbearia tem entrada pela via pública. Entrou na casa com o seu parceiro policial, após o réu informar que tinha mais drogas em frente à sua casa. O próprio acusado pegou a droga. O foi alertado do seu direito de ficar calado, sendo que na abordagem a mãe e a irmã do réu estavam em casa. Houve a autorização do réu para entrada na residência e o uniforme não tem câmeras em seu uniforme porque não houve fornecimento pelo Estado. Tinha pessoas na rua, mas não ficaram. Depois apareceram a irmã e a mãe.

A testemunha defensiva Layane Melo de Jesus Santos, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que conhece o réu porque ele mora no morro mas não tem amizade íntima com ele. Às reperguntas da Defesa disse que a sua família tem uma mercearia na esquina da sua do réu. Presenciou a entrada dos policiais na residência do réu, que estava dentro de casa. Tinha três policiais na viatura, sendo que os policiais chutaram o portão e entraram. Não sabe descrever o policial, apenas indicando que era o policial menos "fortinho", branco mais baixo e mais careca. O policial moreno e mais forte e mais alto ficou do lado de fora do portão. Não viu o réu abrindo o portão.

A testemunha defensiva Vania Maria dos Santos, ouvida na condição de informante por ser mãe do réu, narrou que a barbearia do réu é na frente de sua casa, nos fundos, sendo necessário abrir o portão para entrar dentro de casa.

O réu Silmar Martiniano, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, negou os fatos que ora lhe são imputados na denúncia, dizendo que no dia dos fatos estava dentro de casa com sua esposa. Não foi trabalhar no dia, pois sua esposa estava passando mal em decorrência da gravidez. Estavam dormindo, quando acordou com a luz de uma lanterna em seu rosto. Os policiais pediram para ir para a sala, quando o miliciano Diogo pediu para mostrar a "peça". Negou que estivesse mexendo com coisas erradas, informando que trabalhava na sua barbearia e em finais de semana trabalhava em um restaurante. Foi levado na delegacia, quando descobriu que ia responder um processo de tráfico de drogas. Viu os entorpecentes apenas na delegacia. Às reperguntas do Ministério Público disse que não viu a droga e não a reconhece como sendo sua. O policial Diogo já o prendeu anteriormente. Às reperguntas da Defesa disse que não havia entorpecentes dentro de sua residência. Não pode dar depoimento na delegacia, tendo sido jogado direto no "corró".

Pois bem.

Os policiais prestaram depoimentos coesos, em conformidade com as provas dos autos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que os mesmos tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.

Vê-se, pois, que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo confirmaram a prática do delito de tráfico de drogas e estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em falta de provas. Ademais, nada há que pudesse, ainda que superficialmente, colocar em dúvida a lisura do trabalho policial, pelo que o decreto condenatório é solução inevitável.

Existe um nexos íntimo entre o ônus de provar e o ônus de alegar, de modo que, estando as partes em condição de igualdade, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar. Desta forma, não há qualquer elemento indicativo que pudesse colocar em xeque a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

Em seu interrogatório judicial, o acusado disse que as drogas não eram de sua propriedade, alegando que as drogas não foram encontradas em sua residência. Completou que trabalharia como barbeiro e aos finais de semana prestaria serviço em um restaurante, contudo não comprovou qualquer atividade lícita.

Como se não bastasse, as testemunhas defensivas também não trouxeram versão consistente com as demais provas dos autos. A mãe do acusado, presente no momento da abordagem, não corroborou a fala do réu acerca da dinâmica dos fatos.

Percebe-se, no discurso, o nítido intuito de eximir-se da responsabilização penal, razão pela qual a versão por ele apresentada não pode ser aceita.

A doutrina majoritária entende que:

"Cabe provar a quem tem interesse em afirmar. A quem apresenta uma pretensão cumpre provar os fatos constitutivos; a quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas. A prova da alegação (onus probandi) incumbe a quem a fizer (CPP, artigo 156, caput). Exemplo: cabe ao Ministério Público provar a existência do fato criminoso, da sua realização pelo acusado e também a prova dos elementos subjetivos do crime (dolo ou culpa); em contrapartida, cabe ao acusado provar as causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como circunstâncias atenuantes da pena ou concessão de benefícios legais". GN

Dessa forma, o exercício de autodefesa processual restou isolado, incongruente e inverossímil se confrontada com o restante das provas constantes dos autos, pelo que merece ser afastado.

Ressalte-se que os policiais disseram que localizaram os entorpecentes na posse do réu, que estava em via pública. Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Supremo Tribunal Federal (HC 87.662-PE, Rel. Min. CARLOS BRITO, j.5.9.06) e no Superior Tribunal de Justiça (REsp. 151.150-SC, Rel. Min. JOSÉ DANTAS, j. 7.4.98).

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecente TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - O testemunho dos policiais tem validade como qualquer outro - Depoimentos coerentes - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - A quantidade da droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias em que se deu a prisão são fatores que, associados à prova produzida, levam à certeza de que o réu efetivamente se dedicava à mercancia de entorpecentes - PENA - MULTA - QUANTUM - INCONSTITUCIONALIDADE - INOCORRÊNCIA - O preceito secundário do crime de tráfico ilícito de drogas não fere os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena - A quantidade da pena de multa cominada ao tipo penal em questão guarda relação com sua gravidade - Opção de política criminal adotada pelo legislador no combate ao tráfico ilegal de entorpecentes - Julgador que, no momento do cálculo da pena, deverá observar as especificidades do caso concreto - Condenação mantida- RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO" (TJSP Ap.n. 0084921-43.2010.8.26.0000 - 15ª Cam. Direito Criminal Rel. AMADO DE FARIA j. 16.12.2010).

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Assim, bem demonstrada a responsabilidade criminal do réu, resta a fixação de sua pena, até porque inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que o isente de sanção.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, dado que não ostenta maus antecedentes, conforme FA de fls. 72/74 e 75/76. Quanto à quantidade e natureza das drogas apreendidas com o acusado, ainda que notadamente relevantes, serão apenas sopesadas na terceira fase da dosimetria a fim de evitar possível bis in idem.

Na segunda fase de fixação da pena, observo que o réu é reincidente (processo nº 1500209-59.2020.8.26.0587 – fl. 75), motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6, tornando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, verifico ser inaplicável ao presente caso a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a existência de indícios concretos de que o acusado se dedica às atividades criminosas, considerando a reincidência do acusado, pelo que consta de sua folha de antecedentes já mencionada. Ausentes demais causas de aumento ou de diminuição de pena, torno-a definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado, devido a gravidade em concreto do crime, delito equiparado a hediondo, bem como pela reincidência, circunstâncias judiciais negativas e preponderantes, que não recomendam a adoção de regime mais benéfico para cumprimento de pena.

No tocante ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deixo de aplicar por ora a detração ou a progressão de regime, pois é matéria de competência da VEC, uma vez que não há substratos fáticos para aferir os requisitos subjetivos necessários. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, não há vício na presente sentença ou violação à regra constante no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu (REsp nº 1.843.481-PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021).

Não é caso de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois ausentes seus requisitos, considerando a quantidade de pena aplicada e a reincidência. Pelos mesmos motivos, sobretudo pela quantidade de pena aplicada, não há que se falar em suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condeno o acusado S. M., qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão regime inicial FECHADO e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu.

Denego ao réu o direito de apelar em liberdade. Ele permaneceu preso durante a instrução em razão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, cujos fundamentos ratifico nessa oportunidade. Considerando ainda as circunstâncias judiciais negativas já mencionadas na dosimetria da pena, a custódia cautelar do

réu permanece necessária para a garantia da ordem pública. Aliás, se antes do julgamento de mérito que considerou o acusado culpado estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação - TJSP, MS 113.332-3, Rel. Reynaldo Ayrosa.

Expeça-se guia de recolhimento provisória caso haja recurso interposto por qualquer das partes, encaminhando-a ao Juízo das Execuções Criminais competente e recomende-se o acusado na prisão onde está recolhido.

Oficie-se à delegacia, autorizando a destruição das drogas apreendidas.

Sem prejuízo da expedição do necessário para intimação pessoal do réu, expeça-se o necessário quanto aos valores e às drogas.

Cumpra-se.

Condeno o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003.

Transitada em julgado a presente decisão, realizem-se as comunicações de praxe.

P. I. C.

Sao Sebastiao, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA